

TD en Responsabilité civile
Licence 2 – Division A (matière dispensée par Madame E. OOSTERLYNCK)

TD. Dani EL HABEL

SÉANCE 2 Le préjudice
--

Fiche d'arrêt :

Le préjudice certain et la perte de chance

Arrêt Civ. 1^{ère}, 21 nov. 2006, perte de chance réparable : disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

Le préjudice direct et les prédispositions de la victime

Arrêt Pathologie cardiaque, Cass. crim., 30 janvier 2007, droit à réparation ne peut être réduit en raison des prédispositions

Commentaire d'arrêt :

Le préjudice direct et le préjudice par ricochet

Arrêt Civ. 2^{ème}, 11 mars 2021, pas de préjudice de l'enfant non conçu au moment du décès de la victime directe

Un préjudice certain

1/ Le principe : seul le préjudice certain est réparable

En droit de la responsabilité civile, le préjudice ne peut être réparé que s'il est certain. Cela signifie que la victime doit établir l'existence réelle et effective du dommage.

⇒ **Ce qui est exclu**, ce n'est pas le dommage futur, mais le dommage purement éventuel, c'est-à-dire celui dont la réalisation demeure hypothétique.

Autrement dit :

- Préjudice certain → réparable
- Préjudice éventuel → non réparable

La certitude ne renvoie donc pas à une exigence absolue, mais à l'idée que le dommage ne doit pas être incertain quant à sa réalisation.

2/ La portée de la certitude : une conception souple

La jurisprudence adopte une lecture finaliste de la certitude, guidée par la fonction indemnitaire de la responsabilité civile.

Ainsi, un dommage est certain :

- Soit parce qu'il s'est déjà réalisé (préjudice actuel),
- Soit parce qu'il se réalisera nécessairement (préjudice futur certain),
- Soit encore parce que la disparition d'un avantage ou d'une probabilité favorable est acquise.

3/ Les manifestations classiques du préjudice certain

A. Le préjudice actuel

Le dommage actuel est celui qui s'est déjà produit. Une telle situation ne soulève point de difficulté notamment en ce qui concerne l'indemnisation des victimes. Mais quid lorsque le dommage ne s'est pas encore réalisé ? Peut-on réparer un préjudice futur ?

B. Le préjudice futur

Le préjudice futur est parfaitement réparable, à condition que sa réalisation soit certaine.

=> Ce qui est exclu alors, c'est le préjudice futur éventuel, dont la réalisation n'est pas certaine.

Exemple type :

Un dommage futur est réparable lorsqu'il apparaît comme la prolongation directe et certaine d'un état actuel, et qu'il peut être évalué immédiatement.

Cas de figure illustratif : Cass. 2e civ., 3 mars 1993, n°91-17.200.

Des propriétaires d'immeubles découvrent que leurs biens sont construits au-dessus d'une ancienne carrière de calcaire asphaltique.

À la suite de plusieurs effondrements du sol, une partie du territoire communal est classée en zone de risque.

Les expertises révèlent que :

- Les tassements du sol vont se poursuivre, de manière lente et irrégulière,
- Ces mouvements peuvent connaître des accélérations brutales, imprévisibles et dangereuses,
- Le sous-sol est déconsolidé de façon irréversible,
- Les immeubles seront, à plus ou moins brève échéance, exposés à de graves désordres, voire à un effondrement les rendant inhabitables.

La question qui se posait était donc de savoir si les propriétaires peuvent invoquer un préjudice certain, alors même que les dommages les plus graves ne se sont pas encore entièrement réalisés. La Cour de cassation a jugé que les propriétaires justifiaient d'un préjudice certain, dès lors que la réalisation future des dommages est inéluctable, même si leur échéance exacte est incertaine.

4/ Le manque à gagner : la perte de chance

Le préjudice certain ne se limite pas à une perte subie : il peut aussi résider dans un gain manqué, qualifié de perte de chance.

Se pose donc la question de savoir si une probabilité est en soit suffisante pour relever de la certitude...

Définition

La perte de chance correspond à la disparition actuelle et certaine d'une probabilité d'événement favorable, même si la réalisation de cet événement était, par nature, incertaine.

=> Ce qui est réparé n'est pas l'avantage final, mais la chance elle-même.

5/ Les conditions de la perte de chance

Pour être réparable, la perte de chance doit répondre à plusieurs exigences :

1. **L'existence d'une éventualité favorable réelle.** La victime devait être placée dans une situation objective de chance.
2. **La disparition certaine et irréversible de cette chance.** La chance ne doit plus pouvoir se représenter.
3. **Le caractère sérieux de la chance perdue.** Une simple espérance ou une hypothèse abstraite ne suffit pas.

⇒ Dès lors que la disparition de l'éventualité favorable est établie, le préjudice est présumé certain.

6/ La réparation de la perte de chance

La réparation est nécessairement partielle :

- Elle est proportionnelle à la probabilité de réalisation de l'événement favorable,
- Elle ne peut jamais être égale à l'avantage espéré.

Il ne s'agit donc pas d'une atteinte au principe de réparation intégrale, car :

- Seule la chance perdue est certaine,
- L'événement final ne l'est pas.

7/ Perte de chance de gagner un procès

La perte d'une chance de gagner un procès est sans doute l'une des principales applications, en témoigne la jurisprudence.

L'étude de cet arrêt va nous permettre de voir comment la Cour de cassation applique concrètement cette conception souple de la certitude, et jusqu'où elle accepte d'indemniser l'aléa, sans jamais réparer l'hypothétique.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ;

Attendu que les époux X... Y... ont engagé une action en responsabilité contre M. Z... qui les avait représentés dans une procédure les opposant à M. A..., reprochant à l'avocat de leur avoir fait perdre la chance d'obtenir la cassation de la décision rendue dans cette affaire ;

Attendu que pour condamner M. Z... à réparation, l'arrêt attaqué retient qu'après avoir conseillé à ses clients de former un pourvoi, l'avocat, par son inertie, leur avait fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation de la décision ayant accueilli, en dépit de leur caractère tardif, les dernières conclusions de M. A... invoquant un nouveau moyen jugé fondé ;

Qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les intéressés disposaient encore de la possibilité de se pourvoir contre la décision litigieuse, signifiée par un acte dont la mention relative au délai du recours en cassation était erronée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; **Motivation**

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; **Dispositif**

Faits : il s'agit de particuliers / clients / plaideurs (qualification juridique des parties à l'instance) qui reprochaient à leur avocat d'avoir manqué une occasion d'obtenir la censure d'un arrêt qui leur ait défavorable ; cela en ne formant pas de pourvoi à temps.

(Autrement dit que s'est-il passé à l'origine du litige ? pourquoi la juridiction a-t-elle été saisie ?)

Procédure : ces plaideurs intentent donc une action en responsabilité contre ledit avocat. Les juges du fond avaient favorablement accueilli leur demande. Par un arrêt du 21 mars 2005, la cour d'appel de Bordeaux condamne l'avocat à réparation au motif qu' « *après avoir conseillé à ses clients de former un pourvoi, l'avocat leur aurait, du fait de son inertie, fait perdre une chance sérieuse d'obtenir la cassation de la décision* ».

(C'est-à-dire quelle a été la solution rendue par les juges du fond avant qu'un pourvoi en cassation ne soit formé ? qui a formé le pourvoi devant la Cour de cassation ?)

Problématique : la responsabilité d'un avocat peut-elle être engagée sur le fondement de la perte de chance lorsque ce dernier concourt à la disparition d'une éventualité favorable actuelle mais incertaine ?

(C'est-à-dire la question à laquelle les juges ont eu à répondre dans cette décision, le problème de droit qui se pose. Pour dégager le problème juridique, résumez brièvement au brouillon les arguments qui s'opposaient devant la Cour de cassation et réfléchissez à la question qui s'en dégage.)

Solution : la Cour de cassation censure les juges du fond, car dans la mesure où il était constant que « les intéressés disposaient encore de la possibilité de se pourvoir contre la décision litigieuse », ils ne pouvaient alléguer une perte de chance « réparable » au sens de la constatation du premier attendu.

(Suit-elle la position de la Cour d'appel ou au contraire censure-t-elle la décision des juges du fond ? Attention, la solution adoptée dans l'arrêt que vous analysez doit répondre à la problématique que vous avez dégagée juste avant. Une fois la solution identifiée, ayez le réflexe de relire rapidement le problème juridique que vous avez formulé afin de vérifier que vous avez bien cerné la problématique, et que vous l'avez bien formulée).

* **Antécédant** : Il faut noter que ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation rappelle cette règle de bon sens. Sa deuxième Chambre civile avait déjà rendu une solution identique dans une hypothèse dans laquelle le demandeur soutenait que la faute du défendeur lui avait fait perdre une chance de réussir un concours d'entrée dans un établissement d'enseignement. Sa demande a été écartée parce qu'il n'avait pas « usé de la faculté qui lui était offerte de se présenter trois fois au concours ».

* **Éclairage** : La perte de chance pourrait être considérée comme heurtant le principe selon lequel le préjudice doit être certain. Toutefois, l'acceptation de ce tempérament doit elle aussi être conditionnée à la certitude de la chance perdue. Exemple : un transporteur ne livre pas la voiture de course d'un individu à temps pour qu'il puisse participer à une course de F1 ; la faute du transporteur prive alors ce sportif de la chance d'obtenir le premier prix. **ET** lorsque la perte de chance est trop incertaine, elle n'est alors pas réparée. Exemple : en cas de décès d'un enfant mineur par accident de voiture, il a été jugé que la chance dont aurait été privée la mère de bénéficier d'une amélioration de ses ressources lorsque son enfant aurait travaillé n'était pas sérieuse et le préjudice non réparable (car éventuel et incertain) : en effet il était trop incertain que l'enfant, encore écolier au jour de son décès, aurait un jour contribué à l'amélioration des ressources de sa mère.

Cet arrêt dresse les conditions d'une indemnisation sur la base d'une perte de chance. Pour que la perte d'une chance constitue un préjudice réparable, il est nécessaire que la chance ait bien été perdue... A contrario, si la prétendue victime peut encore agir pour éviter que la chance dont elle dispose disparaisse, aucune chance n'est alors encore perdue et elle ne peut obtenir réparation d'un préjudice par hypothèse inexistant. En l'espèce, l'inertie de leur avocat n'avait pas fait perdre aux plaideurs une chance d'obtenir la cassation de la décision qui leur était défavorable, puisqu'en dépit de la négligence de ce dernier, le délai pour se pourvoir en

cassation n'était pas expiré. La faute de leur conseil n'avait donc pas empêché l'événement favorable de se produire et n'avait anéanti aucune chance.

* Analyse : On peut critiquer la solution rendue par la Cour de cassation et considérer que dès lors que le défendeur a amoindri les probabilités qu'avait l'événement de se réaliser, il y a perte de chance, même si le demandeur pouvait encore le faire se produire. Mais la Cour a estimé qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance « réparable ». Pourquoi ? Tout simplement car l'indemnisation de la perte de chance est déjà une entorse à l'exigence de certitude du préjudice.

Un préjudice direct

La question de la réparation des préjudices par ricochet. Le caractère direct du préjudice soulève la question de la réparation des préjudices subis par ricochet. Le principe est le suivant : tout préjudice doit découler directement du dommage pour être réparable.

- Peut-on à cet effet parler de préjudice direct lorsque l'on est en présence d'un lien de causalité « distendu » ?
- Les dommages en cascade, c'est-à-dire affectant une victime initiale et une ou plusieurs victimes par ricochet, peuvent-ils être réparables ?

La jurisprudence est à cet égard particulièrement souple s'agissant de la détermination des victimes par ricochet.

- ⇒ Est donc considéré comme réparable, tant le préjudice subi par les victimes directes que par les victimes indirectes, lesquelles subissent un préjudice propre « par ricochet », en raison de l'existence d'un dommage ayant atteint la victime directe.

Nature du préjudice par ricochet. La problématique de victime par ricochet invite à se situer vis-à-vis de la comparaison déjà évoquée entre dommage et préjudice. A cet effet, une question peut légitimement apparaître : la victime par ricochet subit-elle un dommage ? En effet, une victime pourrait subir un préjudice sans forcément subir elle-même de dommage. Il en serait ainsi du préjudice d'affection éprouvé à la suite de la perte d'un être cher. Sauf à retenir un dommage totalement insaisissable, la victime par ricochet n'a subi aucun dommage. Si un dommage est identifiable, celui-ci a uniquement visé la victime initiale. En l'occurrence, il s'agira ici de son décès. C'est donc au niveau du préjudice qu'il faudra se positionner. A cet effet, ce préjudice peut être de nature patrimoniale (par exemple quand le dommage corporel de la victime directe a entraîné une perte de revenus pour ses proches) ou extrapatrimoniale (le cas du préjudice affectif subi par les proches de la victime directe d'un dommage corporel) : préjudice d'affection.

L'indemnisation du préjudice par ricochet comme tempérament. Également dans certains cas, un préjudice par ricochet peut être réparable. Quant est-il dans *l'Arrêt Civ. 2ème, 11 mars 2021 Pourvoi n° P 19-17.384* : pas de préjudice de l'enfant non conçu au moment du décès de la victime directe.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2018), et les productions, E... S..., née le [...], a disparu le 8 juillet 1987.
2. L'information judiciaire ouverte du chef d'enlèvement de mineur de 15 ans a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu en janvier 1989. L'information ayant été reprise des chefs d'enlèvement et séquestration de plus de sept jours, un second non-lieu a été prononcé en novembre 2014, à la suite duquel la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information.
3. Mme U... S..., soeur de E... S..., née le [...], se prévalant des faits d'enlèvement et de séquestration qui auraient été commis à l'encontre de cette dernière, a saisi, le 4 décembre 2015, une commission d'indemnisation des victimes d'infractions, aux fins de versement d'une provision en réparation de son préjudice moral, sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Exposé du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt d'allouer à Mme U S la somme provisionnelle de 12 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral alors «que n'existe aucun lien de causalité entre la disparition de la victime et le préjudice prétendument souffert par sa sœur née plusieurs années après cette disparition ; qu'en allouant néanmoins à Mme S la somme provisionnelle de 12 000 euros au titre du préjudice moral résultant de la disparition de sa sœur, après avoir pourtant constaté que Mme S était née près de quatre ans après cette disparition, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale»

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et l'article 706-3 du code de procédure pénale :

5. Aux termes du premier de ces textes, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et, selon le second, sous certaines conditions, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne.
6. Pour allouer à Mme U... S... une provision au titre de son préjudice moral, l'arrêt retient qu'en raison de sa naissance au sein d'une famille marquée par la disparition inexplicquée d'une enfant de 10 ans, Mme U... S... a dû se construire avec le traumatisme de cette disparition, entretenu en permanence au sein du foyer familial.
7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme U... S... avait été conçue après la disparition de sa sœur, de sorte qu'il n'existait pas de lien de causalité entre cette disparition non élucidée et le préjudice invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. En l'absence de lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice allégué, la demande de provision formée par Mme U... S... doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Faits : Le 8 juillet 1987, une jeune fille âgée de 10 ans a disparu à la suite d'un enlèvement. La sœur de cette jeune fille demande réparation de son préjudice moral subi à la suite de cet événement traumatisant.

Procédure : La sœur de la disparue, née 3 ans après l'enlèvement présumé de la jeune fille, va saisir une CIVI pour demander réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. La cour d'appel ayant admis le droit à réparation, le Fonds de garantie des victimes et d'autres infractions (FGTI) forme un pourvoi en cassation.

Problématique : Un enfant conçu après la disparition de sa sœur peut-il obtenir réparation du préjudice que lui cause cette disparition ?

Solution : la deuxième chambre civile, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, refuse d'admettre le lien de causalité entre la disparition de l'enfant et le préjudice moral de sa sœur qui n'était pas conçue au moment de la survenance du fait générateur.

*** Analyse :**

La réparation du préjudice d'un enfant non encore né au moment du fait dommageable ?

La question du droit à indemnisation du préjudice par ricochet d'un enfant qui n'était pas encore né au moment d'un fait dommageable a été abordée à plusieurs reprises par la Cour de cassation. L'évolution de la jurisprudence a montré des revirements, avant d'aboutir à une solution plus restrictive dans l'arrêt rendu le 11 mars 2021.

1. Les premières décisions : un refus d'indemnisation

Dans un premier temps, la Cour de cassation refusait d'indemniser le préjudice par ricochet d'un enfant né après le fait dommageable. La raison principale était l'absence de lien de causalité entre l'événement initial (exemple : un accident entraînant le décès ou le handicap d'un parent / à savoir la victime directe) et le préjudice moral de l'enfant, qui n'existait pas encore au moment des faits.

Ainsi, un enfant né après la mort de son père ou après qu'un accident ait rendu ce dernier handicapé ne pouvait pas demander réparation de son préjudice moral. Même si l'enfant avait été conçu au moment des faits, cela ne changeait rien (Cass. 2e civ., 4 nov. 2010, 09-68.903).

2. Le revirement de jurisprudence : une ouverture vers l'indemnisation

Dans un second temps, la Cour de cassation a changé de position. Elle a admis qu'un enfant qui était déjà conçu au moment du fait dommageable pouvait obtenir réparation du préjudice moral qu'il subit et qui résulte de la mort ou le handicap de la victime directe. L'argument repose sur le principe *infans conceptus*, qui permet de considérer un enfant conçu comme déjà existant en matière de droits successoraux ou de réparation.

Ce revirement a été initié par la deuxième chambre civile en 2017 (Cass. 2e civ., 14 déc. 2017) et confirmé par la chambre criminelle en 2020 (Cass. crim., 10 nov. 2020).

La jurisprudence a même été étendue à des petits-enfants : la Cour de cassation a admis l'indemnisation d'un enfant qui n'était pas encore né mais dont le grand-père était décédé dans un accident de la route avant sa naissance (Cass. 2e civ., 11 févr. 2021).

3. L'arrêt du 11 mars 2021 : un frein à l'élargissement du champ d'indemnisation des victimes indirectes

Dans l'affaire ci-contre, la Cour de cassation a dû se prononcer sur le cas d'une jeune fille née trois ans après la disparition de sa sœur aînée. Elle demandait réparation pour son préjudice moral, en expliquant que la souffrance causée par cette disparition était constamment présente dans sa famille.

La Cour a refusé d'accorder une indemnisation, en rappelant une distinction essentielle :

- Si l'enfant était déjà conçu au moment du fait dommageable, il pouvait être indemnisé.
- Si l'enfant n'était pas encore conçu, il ne pouvait pas l'être.

Autrement dit, la date de conception devient le critère décisif : l'enfant doit avoir été conçu avant l'événement pour prétendre à une indemnisation. La Cour de cassation a donc limité l'élargissement du cercle des victimes par ricochet.

* Plan :

I./ Le rejet de l'indemnisation du préjudice moral de l'enfant non-conçu au moment du fait dommageable

A./ La conception comme première condition du droit à indemnisation du préjudice par ricochet

La victime par ricochet prétendait à la réparation de son préjudice moral consistant dans le traumatisme de la disparition entretenu en permanence au sein du foyer familial. Or la particularité réside dans le fait que si la victime par ricochet était simplement conçue au moment de la disparition de sa sœur, son droit à indemnisation ne poserait guère de difficulté si l'on suit les dernières évolutions jurisprudentielles.

Mais ici la situation était différente ; la victime par ricochet n'était pas conçue au moment de l'enlèvement. Aussi, la deuxième chambre civile, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil et de l'article 706-3 du Code de procédure pénale, refuse d'admettre le lien de causalité entre la disparition de l'enfant et le préjudice moral de sa sœur qui n'était pas conçue au moment de la survenance du fait générateur.

=> La Cour de cassation place le curseur à la date de la conception et non la date de la naissance

B./ La conception antérieure au fait dommageable comme seconde condition de réparation

Mais pour tirer profit du préjudice subi par la victime indirecte et accéder à la réparation de son préjudice moral, l'enfant doit avoir été conçu antérieurement au fait dommageable et non postérieurement à ce dernier.

La reconnaissance d'un préjudice moral des victimes par ricochet implique principalement que le dommage dont la victime par ricochet entend tirer un préjudice se soit produit pendant sa vie. Or la capacité de jouissance d'une personne physique a pour point de départ la naissance. D'où le recours au principe d'*infans conceptus* afin de faire comme si l'enfant est né lorsqu'il y va de son intérêt.

- ⇒ Par application de ce principe, l'enfant conçu est considéré comme né, il est donc acquis de pouvoir indemniser le préjudice moral qu'il subit.

- ⇒ D'où la distinction à établir entre un enfant conçu au moment du fait dommageable et un enfant non-conçu, le premier seul apte à accéder à la réparation, uniquement du fait de l'application du principe.

II./ Une solution angulaire dans la construction du régime juridique propre à l'indemnisation des victimes par ricochet

A./ La consécration d'une limite à l'indemnisation du préjudice moral des enfants non-conçus

Les derniers arrêts de la Cour de cassation en la matière indiquent un certain libéralisme excessif notamment lorsqu'il s'agissait d'admettre la réparation du préjudice moral de la victime par ricochet résultant du décès de son grand-père : Cass. 2e civ., 11 févr. 2021, n° 19-23.525.

⇒ La Cour de cassation vient alors freiner cet élan en encadrant ce cas particulier d'indemnisation. Donc si elle s'inscrit dans la même lignée que les arrêts précédents, elle n'opère toutefois pas un saut dans l'excès en ce que ce sont uniquement les conditions d'application de la règle *infans conceptus* qui vont permettre l'établissement du lien de causalité.

⇒ On voit bien que la Cour n'empiète pas sur cette règle pour aller encore plus loin dans l'admission d'une indemnisation. Et en même temps, elle rompt avec la solution de 2005 qui place plutôt le curseur à la date de naissance de l'enfant.

B./ Critique : le caractère contestable de l'admission du droit à indemnisation de la victime simplement conçue ?

C'est la distinction entre un *enfant conçu* et un *enfant non encore conçu* qui soulève plusieurs interrogations :

D'un point de vue humain, la douleur ressentie par un enfant qui grandit dans une famille marquée par un drame (dans notre cas il s'agit de l'impossibilité de nouer une relation affective avec la victime directe qui vient matérialiser le préjudice moral) est-elle différente selon qu'il était déjà conçu ou non ?

- ⇒ Le fait que l'enfant fut conçu ou pas au moment de la disparition d'un membre de sa famille ne changera rien aux souffrances qu'il pourra subir.

D'un point de vue juridique, le préjudice par ricochet doit refléter celui de la victime principale. Or, si l'enfant n'était pas encore né au moment du fait dommageable, comment pourrait-il avoir subi un préjudice directement lié à cet événement ?